

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº 11/2013

- Acusados: Eagle Capital Ltda.
Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
Ivany Yara de Medeiros
Mauro César Medeiros de Mello
- Ementa: Irregularidades na administração e na gestão de clubes de investimento. Prática de negociação excessiva (*churning*). Negligência na defesa dos direitos e dos interesses de clubes de investimento administrados pela Corretora. Absolvições e Multa.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

PRELIMINARMENTE, rejeitar as arguições de prescrição quinquenal e de prescrição intercorrente apresentadas pela defesa, e

NO MÉRITO:

1. Aplicar à **Geração Futuro Corretora de Valores S.A.** a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), pelo giro excessivo de negócios nas carteiras dos clubes de investimento por ela administrados (*churning*), em infração ao artigo 16, inciso VI, da Instrução CVM nº 306/1999;
2. ABSOLVER a Geração Futuro Corretora de Valores S.A. de todas as demais acusações relativas a irregularidades na administração e na gestão de clubes de investimento - tais como, por exemplo, negligência na defesa dos direitos e interesses dos clubes de investimento e descumprimento do dever de diligência - bem como absolvê-la da imputação de infração a dispositivos da Instrução CVM nº 40/84.
3. ABSOLVER Mauro César Medeiros de Mello da imputação de infração aos artigos 7º e 9º da Instrução CVM nº 40/84, bem como das acusações de negligência na defesa dos direitos e interesses dos clubes de investimento e de descumprimento do dever de diligência.

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto nº 8.652, de 2016, a decisão de absolvição transita em julgado na primeira instância, dessa forma, a CVM não mais interpõe recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Proferiu defesa oral o advogado Carlos Augusto Junqueira de Siqueira, representante dos acusados Mauro César Medeiros de Mello e Geração Futuro Corretora de Valores S.A.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi dos Santos, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Borba.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 11/2013

Acusados: Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
Mauro César Medeiros de Mello

Assunto: Apurar eventuais irregularidades na gestão e na administração de clubes de investimento.

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I. OBJETO.

1. Este Processo Administrativo Sancionador foi instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores ("SPS") e pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM ("PFE") para apurar eventuais irregularidades na gestão e na administração de clubes de investimento.

2. A Geração Futuro Corretora de Valores S.A. ("Geração Futuro") é acusada de violar o artigo 16, inciso VI, da Instrução CVM nº 306/99¹; o artigo 16, inciso VII, c/c o art. 14, inciso II, da Instrução CVM nº 306/99², e, em conjunto com o seu diretor, Mauro César Medeiros de Mello ("Mauro de Mello" e, em conjunto com Geração Futuro, os "Acusados"), acusada de violar os artigos 4º, inciso III, 7º e 9º, da Instrução CVM nº 40/1984³.

3. Em resumo, as acusações formuladas contra a Geração Futuro se referem (i) à prática de negociação excessiva de ativos de clubes de investimento administrados e geridos pela Geração Futuro; (ii) à alegada negligência na defesa dos direitos e interesses de alguns dos clubes de investimento administrados que não tinham descontos nas taxas de corretagem pagas à Geração Futuro enquanto corretora; e (iii) à

inobservância de certos limites e falhas na divulgação de informações exigidos nos normativos editados pela CVM.

4. A acusação inclui, ainda, imputações contra a *Eagle Capital Ltda.* ("Eagle Capital") e Ivany Yara de Medeiros ("Ivany de Medeiros"). A referida gestora e a sua diretora são acusadas de violação ao artigo 14, incisos IV e VII, da Instrução CVM nº 306/1999, em função de alegada retenção, pela Eagle Capital, de rebates de corretagem que deveriam ter sido repassados aos clubes cuja carteira ela geria.

5. Essas acusações não serão analisadas nesse julgamento, dado que, em 22.12.2017, a Eagle Capital e Ivany de Medeiros apresentaram proposta de termo de compromisso. Nos termos do artigo 14, §2º, da Deliberação CVM nº 538/2008⁴, a referida proposta será apreciada em processo apartado (Processo SEI nº 19957.000701/2018-13), onde também será apurada a responsabilidade da *Eagle Capital* e de Ivany de Medeiros caso, ao final, a CVM decida não celebrar termo de compromisso. Ressalto que, nos termos do artigo 2º, inciso IV, da Lei nº 9.873/99, "*interrompe-se a prescrição da ação punitiva (...) por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal*".

II. ORIGEM.

6. Este processo teve origem em investigação realizada pela Gerência de Acompanhamento de Investidores Institucionais 2 ("GII-2") que, em seu acompanhamento regular do mercado, identificou indícios de que um agente autônomo de investimento estaria gerindo ativos de determinado clube de investimento administrado pela Geração Futuro.

7. Dessa forma, em 22.12.2006, a GII-2 elaborou a Solicitação de Inspeção CVM/SIN/GII/Nº22/06⁵, com o objetivo de apurar uma eventual gestão irregular de recursos dos clubes de investimento administrados pela Geração Futuro por pessoas não credenciadas perante a CVM.

8. Ao longo do procedimento de inspeção, a Superintendência de Fiscalização Externa ("SFI") realizou diligências para apurar os fatos, entre os quais intimações em 07.11.2007⁶ e 08.02.2008⁷ para fornecimento de cópias de documentos referentes a diversos clubes de investimento administrados pela Geração Futuro. Em 28.11.2008, a SFI emitiu o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/Nº 006/2008, que versou, entre outros assuntos, sobre a gestão de clube de investimentos por pessoa não autorizada à atividade (agentes autônomos de investimento), sobre prática de negociação excessiva, (internacionalmente conhecida como "*churning*") em detrimento dos clubes avaliados⁸, e sobre o fato de a *Eagle Capital* ter recebido irregularmente 50% (cinquenta por cento) da taxa de corretagem incidente sobre as operações realizadas pelos clubes de investimento PJ Monet e Cézanne.

9. A partir dessa análise, em 04.03.2013, a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais ("SIN") propôs a instauração de Inquérito Administrativo, por julgar necessária a realização de procedimentos adicionais de apuração das possíveis irregularidades.

10. Em 17.05.2013, o Superintendente Geral ("SGE") determinou a instauração de Inquérito Administrativo e a remessa dos autos para a SPS.

III. ACUSAÇÃO.

11. Em sua investigação, a SPS apurou eventuais irregularidades relacionadas (i) à atuação irregular de agentes autônomos como gestores de clubes de investimento; (ii) à prática de negociação excessiva de ativos de clubes de investimento administrados e geridos pela Geração Futuro; (iii) à negligência na defesa dos direitos e interesses dos clubes de investimento, ao não negociar o desconto nas taxas de corretagem geradas pelas operações realizadas por esses clubes administrados pela Geração Futuro; (iv) a outras irregularidades na administração e gestão de clubes de investimentos pela Geração Futuro; e (v) a não devolução aos clubes dos descontos de rebates de corretagem por parte da *Eagle Capital*.

III.1. ATUAÇÃO IRREGULAR DE AGENTES AUTÔNOMOS COMO GESTORES DE CLUBES DE INVESTIMENTO.

12. Com relação ao primeiro conjunto de práticas supostamente irregulares, relacionadas à potencial atuação irregular de agentes autônomos como gestores de clubes de investimentos, a SPS entendeu não ter indícios suficientes para concluir pela efetiva atuação dos agentes autônomos na gestão do Clube Solaris, ou dos Clubes da "Família Gol"⁹. Dessa forma, tal ilegalidade foi afastada por falta de elementos de autoria e materialidade.

III.2. NEGOCIAÇÃO EXCESSIVA.

13. No tocante à prática de negociação excessiva de ativos, a análise feita pela SPS abarcou 25 (vinte e cinco) clubes de investimento administrados pela Geração Futuro investigados no ano de 2007 e indicou uma alta probabilidade de ter ocorrido tal irregularidade em, ao menos, 13 (treze) deles (52%). Em função dos resultados obtidos nessa análise preliminar, a SPS decidiu ampliar a amostra analisada a todos os clubes de investimentos administrados pela Geração Futuro que possuíam patrimônio líquido superior a R\$1 milhão (um milhão de reais) em 31.12.2007 – total de 151 (cento e cinquenta e um) clubes.

14. A análise da Acusação se baseou em três indicadores. Como ponto inicial, a área técnica analisou o comportamento das carteiras a partir de dois indicadores notoriamente utilizados para verificar a caracterização de giro excessivo de ativos de uma carteira de investimentos – a taxa de giro da carteira (*turnover ratio*, "TR") e a razão custo sobre patrimônio (*cost/equity ratio*, "C/E"). Ambos os indicadores foram abordados em estudos elaborados pela BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados ("BSM") e pela Assessoria de Análise e Pesquisa ("ASA") da CVM.

15. A acusação utiliza-se ainda de um terceiro método, que parte de uma análise qualitativa da gestão de uma carteira, analisando o TR e o C/E dos ativos mais negociados por cada um dos clubes. Tal análise foi baseada em outro estudo¹⁰, que sustenta que os índices de análise de giro de carteira devem ser calculados com base no valor médio dos valores mobiliários negociados e não no valor médio da carteira. A partir de tal análise, seria possível verificar negociações excessivas em relação a um (ou alguns) dos ativos da carteira, ainda que essa, na média, não apresente indicadores TR e C/E elevados.

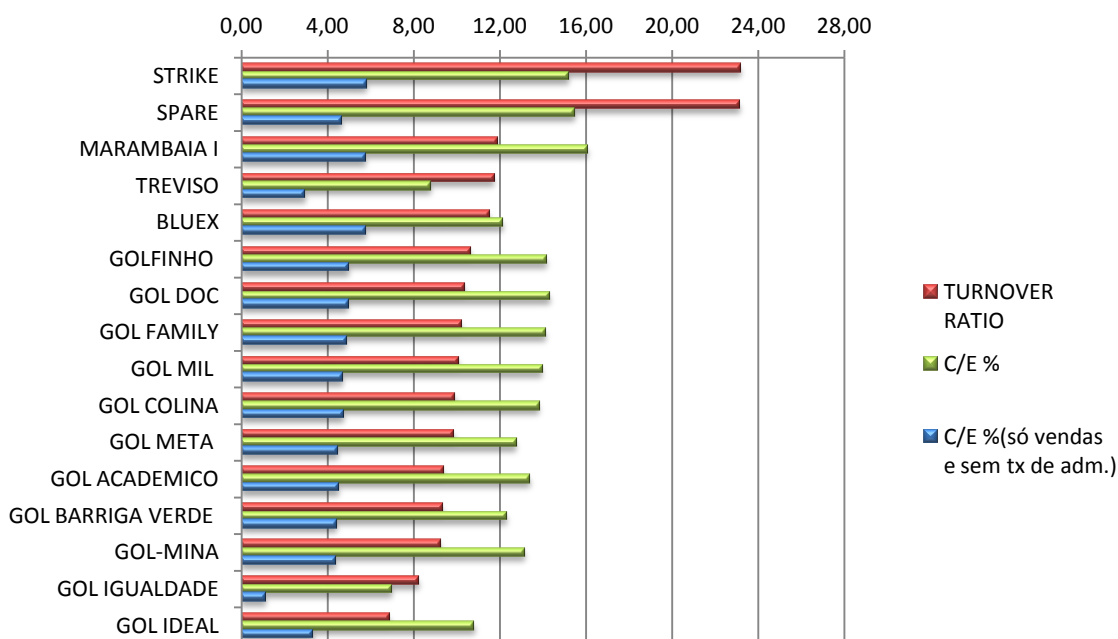
16. A SPS se valeu das três metodologias acima referidas, aplicando-as às carteiras dos clubes de investimento administrados pela Geração Futuro. Em primeiro lugar, foi realizada análise com base no indicador TR dos indicados 151 (cento e cinquenta e um) clubes. A partir desse filtro, a área técnica identificou uma alta probabilidade de

negociação excessiva em 15 (quinze) deles, pois apresentaram TR acima de 8 no período entre janeiro e outubro de 2007.

17. Em seguida, os clubes destacados pelo primeiro filtro foram submetidos à análise do C/E, conforme determina o estudo da BSM. Nesse exame, verificou-se que 14 (catorze) dos 16 (dezesesseis) clubes com TR acima de 8 (oito) apresentaram C/E acima de 4,1% (quatro vírgula um por cento), fato que, na visão da Acusação, corroboraria a alta probabilidade de ocorrência de negociação excessiva.

18. A Acusação excluiu três clubes, em razão de serem geridos por cotistas dos próprios clubes, que não recebiam remuneração. Outros três clubes também foram excluídos em razão da incidência de prescrição, uma vez que tais veículos não haviam sido analisados nas primeiras diligências. Em contrapartida, a acusação incluiu também o clube Gol Ideal, que, embora tivesse um TR inferior a 8 (oito), possuía uma carteira praticamente idêntica e operava nos mesmos dias e em horários próximos aos demais clubes da "Família Gol". Desta forma, a Acusação abarcou dez clubes de investimento, todos da "Família Gol".

19. Os valores para os dez clubes da "Família Gol" variaram entre 1,15% e 4,95% e, na média, o valor de C/E foi de 4,14% no período. A tabela abaixo resume os indicadores TR e C/E dos clubes de investimento da Família Gol, bem como dos demais clubes que apresentaram TR acima de 8 (oito):



20. Embora tenha considerado que os indicadores acima referidos já seriam conclusivos quanto à ocorrência de negociação excessiva de ativos nos 14 clubes de investimento acima referidos, a SPS, por fim, realizou a análise qualitativa, de acordo com o terceiro método proposto. Nessa análise, a área técnica observou que pelo menos um ativo da carteira de cada um dos clubes foi negociado, isoladamente, em volume superior ao próprio patrimônio líquido do clube. Para a Acusação, esse seria mais um forte indício de que o propósito nessas negociações era apenas o de gerar receita de corretagem. A tabela constante do **Anexo 1** resume os principais dados obtidos pela SPS em sua última análise.

21. Adicionalmente, a Acusação afirma que a decisão de investimento dos referidos clubes, na maioria das vezes, obedecia a uma sistemática de comprar o ativo, vendê-lo poucos dias depois, recomprá-lo também após poucos dias e repetir tais passos sucessivamente, sem qualquer fundamentação econômica ou financeira minimamente plausível.

22. A área técnica acusou a Geração Futuro, na qualidade de administradora de carteira de títulos e valores mobiliários, de ter negociado excessivamente ativos que compunham a carteira dos Clubes de Investimento *Gol Doc.*, *Gol Family*, *Gol Mil*, *Gol Colina*, *Gol Meta*, *Gol Acadêmico*, *Gol Barriga Verde*, *Gol Mina*, *Gol Igualdade* e *Gol Ideal*, com o propósito de gerar receita de corretagem, em detrimento dos interesses dos condôminos dos respectivos clubes, em infração à norma do artigo 16, inciso VI, da Instrução CVM nº 306/1999.

III.3. NEGLIGÊNCIA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS CLUBES DE INVESTIMENTO.

23. Em relação às taxas de corretagem cobradas dos diferentes clubes de investimento administrados pela Geração Futuro, a SPS averiguou que a maior parte dos clubes pagava taxa de corretagem no valor de 0,5% (meio por cento), mas, que certos clubes recebiam descontos que variavam entre 50% (cinquenta por cento) e 80% (oitenta por cento) desse valor. Após questionamento, a Geração Futuro afirmou que, em relação às taxas de corretagem cobradas dos clubes, *"a regra era não conceder descontos, tendo em vista o baixo volume de operações realizado. Entretanto, em se tratando dos clubes exclusivos ou familiares, optou-se por conceder rebates"*.

24. A Acusação argumenta que a Geração Futuro, por acumular as funções de administradora dos clubes, gestora das carteiras desses veículos e de instituição intermediária das operações, tinha interesses distintos e contrapostos. Dessa forma, seria legítimo que a Companhia buscasse maximizar seus lucros enquanto instituição intermediária, mas, não na qualidade de gestora da carteira dos clubes a ela vinculados.

25. Diante desses fatos, a SPS entendeu que a Geração Futuro, na qualidade de administradora de clubes de investimentos¹¹, não teria sido diligente na defesa do interesse dos cotistas dos clubes de investimentos "não exclusivos", ou "não familiares", na medida em que não empreendeu esforços para reduzir os custos de corretagem deles, em infração às disposições contidas no artigo 14, inciso II, c/c o art. 16, inciso VII, da Instrução CVM nº 306/1999.

III.4. OUTRAS IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO E NA GESTÃO DE CLUBES DE INVESTIMENTOS PELA GERAÇÃO FUTURO.

26. A área técnica apontou também outras irregularidades na administração de clubes de investimentos pela Geração Futuro, quais sejam: (i) cotistas apresentaram percentual superior a 40% (quarenta por cento) do total de cotas do clube de investimentos, em infração ao artigo 7º da Instrução CVM nº 40/1984; (ii) o clube Programado III contou com 152 (cento e cinquenta e dois) cotistas em janeiro e fevereiro de 2007, acima do limite regulamentar de 150 (cento e cinquenta) cotistas, em infração ao artigo 9º da Instrução CVM nº 40/1984; e (iii) o estatuto social do clube de investimento Cézanne não informou acerca da remuneração pactuada entre a Geração Futuro e a Eagle Capital, gestora da carteira do fundo, embora existisse remuneração para o exercício de tal função, em infração ao artigo 4º, inciso III, da Instrução CVM nº 40/1984.

27. Dessa forma, a SPS acusou (i) a Geração Futuro, na qualidade de administradora dos clubes de investimento *Gol Mil*, *Gol Igualdade*, *Gol Brasil*, *Gol Vida*, *Programado III* e *Cézanne*; e (ii) Mauro Mello, na qualidade de diretor responsável pela supervisão desses clubes, por não cumprirem as mencionadas normas.

IV. DEFESA.

28. Em 12.01.2015, a Geração Futuro e Mauro de Mello apresentaram defesa conjunta (fls. 4.658-4.717).

29. Preliminarmente, os Acusados apontam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, conforme previsto no artigo 1º, *caput*, da Lei nº 9.873/99, pois os fatos tidos como irregulares, ocorridos no ano de 2007, foram apurados tendo em vista uma eventual gestão irregular de clubes de investimento por agentes autônomos de investimento contratados pela Geração Futuro; condutas que, ao final das investigações, conclui-se não terem sido verificadas, e que não consta dos autos qualquer ato investigativo passível de interromper a prescrição quinquenal com relação às imputações realizadas pela Acusação. Nesse sentido, argumentam que é imprescindível que o ato de apuração, para fins de interrupção da prescrição, tenha relação com os fatos supostamente ilícitos, não sendo possível a consideração de ato genérico.

30. Ainda sobre prescrição, os Acusados argumentam que, para a configuração de um ato inequívoco de investigação, deverá sempre ser garantido ao indiciado o conhecimento pessoal do objeto da investigação, de modo a se assegurar o acompanhamento do processo e o direito de defesa. No caso concreto, não teria ocorrido qualquer das hipóteses capazes de interromper o prazo prescricional, visto que os Acusados não tomaram conhecimento dos fatos investigados.

31. Nesse sentido, a defesa pede o reconhecimento da prescrição quinquenal em relação aos fatos considerados irregulares pela Acusação, pois ocorreram em 2007, de modo que a pretensão punitiva da CVM teria se encerrado no ano de 2012.

32. Os Acusados afirmam também que não houve nenhum questionamento prévio ao oferecimento da acusação a respeito das irregularidades na administração de clubes de investimentos pela Geração Futuro relacionadas à Instrução CVM nº 40/1984 (item III.4, *supra*), em violação à norma do artigo 11 da Deliberação CVM nº 538/2008¹².

33. No mérito, os Acusados alegam, em relação à suposta prática de negociação excessiva, que, de acordo com a jurisprudência da CVM e com os próprios estudos utilizados pela Acusação, a mera identificação de TR superior a 8 (oito) não seria suficiente para caracterizar o ilícito, sendo imprescindível a sua corroboração por índices de C/E também elevados. Quanto a este último índice, os Acusados defendem que os estudos de BSM e ASA apresentam divergências significativas quanto aos parâmetros de identificação de custo excessivo. Sustentam também que, embora o estudo ASA tenha identificado que há uma probabilidade inferior a 2,5% de que fundos de investimento em ações apresentem C/E superior a 4,1% a.a. (quatro vírgula um por cento ao ano), em momento algum o estudo da ASA afirmou ser esse um parâmetro para identificação de prática de negociação excessiva.

34. Os Acusados afirmam que, seguindo os parâmetros adotados pelo estudo da BSM, os clubes da Família Gol teriam apresentado C/E de, no máximo, 14% (quatorze por cento) a.a., portanto, abaixo dos 21% (vinte e um por cento) a.a. que a BSM identificou em seu estudo como indicador da infração.

35. Por todo o exposto, os Acusados concluem que *"a Acusação optou por combinar três diferentes critérios embasados em estudos elaborados por órgãos diversos, de modo a escolher de cada um destes estudos, isoladamente, os elementos que melhor sustentam a sua tese acusatória, terminando por formular um critério próprio para a definição de um C/E excessivo"*.

36. Os Acusados afirmam que, mesmo utilizando-se de um "critério combinado", a Acusação seria contraditória, pois dentre os 13 clubes suspeitos, três foram excluídos do Relatório, justamente em razão de a corretora não ter controle sobre as operações que seriam realizadas, uma vez que tais clubes eram geridos por cotistas não remunerados para essa atividade.

37. Além disso, em relação ao clube Gol Ideal (que não se enquadra nos critérios estabelecidos no Relatório), a Acusação teria sido formulada apenas por ter o clube a mesma estratégia de negociação dos demais clubes da Família Gol, configurando uma acusação "por aproximação", que desconsidera o princípio do *in dubio pro reo*.

38. Os Acusados passam, então, à análise das operações realizadas, alegando que elas foram racionais, economicamente justificáveis e obtiveram completo êxito. Para tanto, defendem que várias delas foram lucrativas, e que foram realizadas com espaçamento de meses, e não de dias, como aponta a Acusação. Nesse sentido, apontam que os clubes da 'Família Gol' tiveram rendimento acima do Ibovespa em 2007, mesmo descontados os custos de negociações, bem como obtiveram um rendimento médio superior ao de clubes nos quais a Acusação entendeu não haver qualquer motivação para negociações excessivas.

39. Em relação à acusação de negligência da Geração Futuro, enquanto gestora, na defesa dos interesses dos Clubes, a Defesa afirma que, embora entenda que a concessão de descontos de corretagem é de natureza comercial e compete exclusivamente à corretora, não cabendo ao regulador adentrar esse mérito, a regra geral adotada pelos Acusados é a de não concessão de descontos aos seus clientes e tratar como regra aquilo que é excepcional traria enorme insegurança jurídica a toda a indústria.

40. Apesar de a Acusação ter equiparado este processo ao Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2005/8510, julgado em 04.04.2007, os Acusados sustentam haver diferenças entre o presente processo e o precedente citado, pois aquele caso se tratava de um Fundo de Investimento em Ações, cujo cotista único era um investidor institucional (fundo de pensão), ou seja, um investidor de grande porte, que realizava volume significativo de operações. No presente caso, no entanto, trata-se de clubes de investimento, que são necessariamente formados por até 150 (cento e cinquenta) pessoas físicas, incomparáveis a um investidor institucional.

41. A Acusação, afirmam, foi feita em razão de a Geração Futuro exercer as atividades de administração e de gestão da carteira e também de corretora intermediária das operações realizadas, mas, não haveria qualquer vedação na regulamentação no tocante ao gestor de clubes de investimento ser parte relacionada à corretora que realiza as negociações desse clube.

42. Quanto às três acusações formuladas em relação às outras irregularidades na administração de clubes de investimentos pela Geração Futuro, os Acusados afirmam, resumidamente:

- i) Em relação à extrapolação do limite de 40% (quarenta por cento) de participação por um único acionista no clube, que reconhecem os fatos; no entanto,

em todos os casos, a situação foi regularizada em, no máximo, cinco meses, o que indicaria a diligência dos Acusados em tomar as medidas necessárias para essa regularização. Ainda, a extrapolação do limite por quatro cotistas, em quatro clubes (num ambiente com mais de 300 clubes administrados), por período médio de dois meses, não teria o condão de causar prejuízo aos cotistas do clube, ou ao mercado em geral, e que o instrumento adequado para o regulador exercer a sua competência sobre os fatos seria o ofício de alerta, nos termos da Deliberação CVM nº 542/2008, e não o processo administrativo sancionador.

ii) Em relação à extrapolação do número máximo de 150 cotistas no clube, que reconhecem os fatos, mas, alegam que a extrapolação em dois cotistas em um único clube não pode ser considerada uma conduta grave, até porque perdurou por apenas dois meses e logo foi corrigida.

iii) Em relação à ausência de previsão estatutária quanto à forma de remuneração da *Eagle* no *Clube Cézanne*, que não houve qualquer prejuízo ao clube, ou aos seus cotistas, tendo em vista que a remuneração do gestor não constituía um encargo do clube, mas, do próprio administrador, e que a conduta estaria de acordo com a Instrução CVM nº 494/2011, que revogou a Instrução CVM nº 40/1984 e eliminou a obrigatoriedade da informação da remuneração da administradora, ou da gestora, quando não forem encargos do clube. Por isso, ainda que se entenda que a Instrução CVM nº 40/1984 tenha sido violada, pelo princípio da retroatividade da lei mais favorável, a punibilidade por infração àquele dispositivo estaria extinta.

43. Por fim, a Defesa ressalta, em relação ao Sr. Mauro de Mello, o seu histórico profissional e reputacional e o fato de que jamais foi acusado em qualquer processo administrativo da CVM, e requer a absolvição dos Acusados.

V. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

44. Em 10.02.2015, esse processo foi originalmente distribuído para o Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, cujo mandato se encerrou em 31.12.2016. Por tal motivo, em 03.01.2017, o processo foi redistribuído para o Diretor Gustavo Borba, tendo o Diretor Pablo Renteria então se declarado impedido. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 14.07.2017, o presente processo foi redistribuído e fui designado seu Relator.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

¹ Art. 16. É vedado ao administrador de carteira: (...) VI - promover negociações com os valores mobiliários das carteiras que administra, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si, ou para terceiros;

² Art. 16. É vedado ao administrador de carteira: (...) VII - negligenciar, em qualquer circunstância, a defesa dos direitos e interesses do titular da carteira, ou omitir-se em relação à mesma;

Art. 14. A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários deve observar as seguintes regras de conduta: (...)II - empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão;

³ Artigo 4º. O estatuto do Clube de Investimento deverá dispor sobre as seguintes matérias: (...) III - taxa de administração, se houver; sua base de cálculo e a forma de remuneração do administrador da carteira, se for o caso.

Artigo 7º. Nenhum condômino poderá ser titular de mais de 40% (quarenta por cento) do total das cotas.

Artigo 9º. O número de condôminos por Clube de Investimento será de, no máximo, 150 (cento e cinquenta) pessoas.

⁴ Art. 14. Omissis. §2º - Caso somente parte dos acusados apresente proposta de Termo de Compromisso, ela será apreciada em processo apartado do Processo Administrativo Sancionador, o qual prosseguirá com relação aos demais acusados.

⁵ Fls. 41.

⁶ O Termo de Intimação CVM/SFI/GFE-5/Nº17/07 (fls. 55/56) tratou do fornecimento de cópias de diversos documentos, tais como: estatuto social, balanço patrimonial de clubes de investimento, contratos de prestação de serviços firmados entre a administradora e os gestores de carteira de investimento dos clubes, e razão analítica das receitas auferidas pela corretora em virtude da administração dos clubes.

⁷ O Termo de intimação CVM/SFI/GFE-5/Nº01/08 (fls. 2.443/2.444) tratou do fornecimento de cópias de diversos documentos, tais como: termo de constituição de clubes de investimento, atas de assembleias realizadas pelos clubes, e notas fiscais e RPA dos pagamentos realizados pela Geração Futuro a agentes autônomos de investimento.

⁸ Fls. 10/40. Segundo o item 40 do Relatório: "ao ser remunerado desta forma, o agente responsável pela gestão dos ativos do clube ensejaria eventual giro excessivo da carteira do mesmo com intuito de gerar receitas para si próprio".

⁹ A acusação denominou como "Família Gol" o conjunto dos seguintes clubes de investimento: *Gol Mina; Gol Vida; Gol Ideal; Gol Family; Gol Mil; Gol Acadêmico; Gol Igualdade; Gol Barriga Verde; Gol Meta; Gol Brasil; Gol Colina; Gol DOC; e Gol Sul*.

¹⁰ Estudo denominado "Churning Revisited: Trading Costs and Control", disponível em <<http://www.slcg.com/pdf/workingpapers/Churning%20Revisited.PDF>> e acessado em 14.05.13.

¹¹ Quais sejam: (i) *Gol Mina*; (ii) *5M*; (iii) *Marambaia I*; (iv) *Gol Doc*; (v) *Gol Colina*; (vi) *Golfinho*; (vii) *Gol Family*; (viii) *Gol Acadêmico*; (ix) *Gol Mil*; (x) *Gol Barriga Verde*; e (xi) *SM*.

¹² Artigo 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

ANEXO 1

GIRO INDIVIDUAL DE ATIVOS DOS CLUBES DA "FAMÍLIA GOL"

	Ativo	TR	Giro/PL do Clube	C/E (%) do ativo
GOL DOC	PETR4	15,88	1,51	19,88%
	GGBR4	21,50	1,37	25,50%
	GOAU4	30,98	1,01	34,98%
	VALE5	39,78	0,87	45,12%
	VCPA4	4,50	0,57	8,50%
	USIM5	16,44	0,63	21,24%
GOL GOL FAMILY	GGBR4	15,50	1,49	19,50%
	PETR4	17,37	1,43	21,73%
	VALE5	37,63	1,31	42,96%
	GOAU4	34,66	1,05	38,66%
	VCPA4	8,78	0,69	12,78%
GOL MIL	PETR4	17,73	1,52	21,73%

	GGBR4	18,85	1,20	22,85%
	GOAU4	27,88	1,09	31,88%
	VALE5	24,92	0,94	31,78%
	VCPA4	5,53	0,43	9,53%
GOL COLINA	GGBR4	18,52	1,29	22,52%
	PETR4	16,88	1,32	20,88%
	GOAU4	38,49	1,21	42,85%
	VALE5	44,06	0,94	49,39%
	USIM5	17,80	0,69	22,60%
	VCPA4	3,63	0,45	7,63%
GOL META	PETR4	13,51	1,39	17,88%
	GGBR4	17,27	1,08	21,27%
	GOAU4	20,24	1,28	25,57%
	VALE5	45,80	1,47	52,66%
	VCPA4	3,59	0,44	7,95%
GOL ACADEMICO	GGBR4	14,07	0,86	18,07%
	PETR4	18,00	1,17	22,00%
	GOAU4	40,80	1,00	45,60%
	VALE5	37,82	1,19	44,68%
	USIM5	17,74	0,64	22,54%
GOL BARRIGA VERDE	PETR4	24,32	1,36	28,32%
	GGBR4	13,73	0,99	17,73%
	GOAU4	77,48	0,95	81,84%
	USIM5	14,47	0,68	19,27%
	VALE5	17,10	0,74	23,96%
GOL MINA	GGBR4	13,66	1,38	17,66%
	PETR4	14,72	1,56	18,72%
	GOAU4	39,98	1,05	44,35%
	VCPA4	2,35	0,31	6,35%
	VALE5	32,43	0,71	37,76%
	USIM5	19,47	0,70	24,27%
GOL IGUALDADE	GGBR4	15,73	1,41	19,73%
	PETR4	14,84	1,10	18,84%
	GOAU4	109,00	0,76	113,36%
	VALE5	13,77	0,72	20,63%
	VCPA4	4,96	0,53	8,96%
GOL IDEAL	PETR4	30,43	1,05	34,43%
	GGBR4	10,32	0,88	14,32%
	GOAU4	46,00	0,55	50,00%
	VALE5	29,08	0,65	34,41%
	RAPT4	5,37	0,31	9,37%
	VCPA4	4,24	0,30	8,24%

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 11/2013

Acusados: Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
Mauro César Medeiros de Mello

Assunto: Apurar eventuais irregularidades na gestão e na administração de clubes de investimento.

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

VOTO

I. OBJETO.

1. Este Processo Administrativo Sancionador foi instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores ("SPS") e pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM ("PFE") para apurar eventuais irregularidades na gestão e na administração de clubes de investimento.

2. A Geração Futuro Corretora de Valores S.A. ("Geração Futuro") é acusada de violar o artigo 16, inciso VI, da Instrução CVM nº 306/99; o artigo 16, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, da Instrução CVM nº 306/99, e, em conjunto com o seu diretor, Mauro César Medeiros de Mello ("Mauro de Mello"), é também acusada de descumprir os artigos 4º, inciso III, 7º e 9º, da Instrução CVM nº 40/84.

3. Em resumo, as acusações se referem (i) à prática de negociação excessiva de ativos (*churning*) de clubes de investimento administrados e geridos pela Geração Futuro; (ii) à alegada negligência na defesa dos direitos e interesses de alguns dos clubes de investimento administrados, que não tinham desconto nas taxas de corretagem pagas à Geração Futuro enquanto corretora; e (iii) à inobservância de certos limites e falhas na divulgação de informações exigidas nos normativos editados pela CVM (essa última acusação recai também contra o seu diretor).

4. Cada uma dessas acusações será separadamente analisada neste voto após o exame das preliminares, objeto da próxima seção.

II. PRELIMINARES.

II.1. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA.

5. A defesa suscita duas preliminares referentes à eventual ocorrência de prescrição. Examinarei esses questionamentos antes de passar à análise das questões de mérito.

6. A primeira preliminar é de ocorrência da prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º, *caput*, da Lei nº 9.873/99. A acusação data de 08.09.2014 e as imputações se baseiam em fatos que teriam ocorrido entre janeiro e setembro de 2007.

7. De acordo com o inciso II do artigo 2º da Lei nº 9.873/99, o ato inequívoco de apuração dos fatos é suficiente para interromper a prescrição da pretensão punitiva da CVM. Segundo a jurisprudência desta casa, os atos inequívocos incluem aqueles praticados sem a ciência do investigado¹.

8. No caso em tela, as imputações se relacionam à administração e à gestão de clubes de investimento feitas pela Geração Futuro e/ou pela *Eagle Capital* e há registro nos autos de diversos atos praticados com a finalidade de esclarecer os fatos. Das diligências de investigação iniciais, ocorridas ainda nos anos de 2007 e 2008, destaco:

i. O Termo de Intimação CVM/SFI/GFE-5/Nº17/07, de 07.11.2007 (fls. 55/56) e o Termo de Intimação CVM/SFI/GFE-5/Nº01/08, de 08.02.2008 (fls. 2.443/2.444), que trataram de fornecimento de cópias de diversos documentos relacionados aos clubes de investimento mencionados na peça acusatória; e

ii. O Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/Nº006/2008 (fls. 10/40), emitido em 28.11.2008, que expressamente mencionou (a) a possibilidade de prática de negociação excessiva por gestor de clube de investimento², (b) a presença de mais de 150 cotistas em um único clube (itens 126/129), e (c) as outras supostas irregularidades relacionadas à administração e à gestão dos clubes de investimento selecionados.

9. Posteriormente, em 04.03.2013, foi realizada uma proposta de instauração de inquérito, nos termos do MEMO/CVM/SIN/GIA/Nº 93/13 (fls. 03/07), para que se apurassem de maneira mais detalhada os indícios até então coletados a respeito de: (i) irregularidades supostamente praticadas por agentes autônomos de investimento, (ii) contratação pela Geração Futuro de pessoas não autorizadas à atividade de gestão de carteiras de valores mobiliários e (iii) recebimento indevido, pelo gestor, de 50% de taxa de corretagem incidente sobre operações realizadas em nome de alguns clubes de investimento³. Para tanto, apontou-se a necessidade de oitiva de agentes autônomos, de diretores da Geração Futuro e de Ivany de Medeiros.

10. Em 17.05.2013, determinou-se, por meio da Portaria CVM/SGE/Nº120 (fl. 1), instauração de inquérito administrativo, inaugurando a fase final de investigação, que, por sua vez, contou com diversos atos de apuração, dos quais destaco apenas alguns dos praticados naquele mesmo ano:

i. O OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/Nº094/2013, de 19.07.2013, por meio do qual foram solicitadas informações sobre taxas de corretagem por clube em cada mês, descontos concedidos sobre as taxas de corretagem, total de compras e vendas realizadas por cada clube, dentre outras informações (fls. 4.078/4.079);

ii. O OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/Nº099/2013, de 12.08.2013, por meio do qual foram solicitadas cópias de estatutos dos clubes e de contratos de prestação de serviços de gestão dos clubes (fls. 4.108-4.109);

iii. O OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/Nº100/2013, de 16.08.2013, por meio do qual foram solicitadas cópias dos relatórios analíticos dos clubes de investimento (fls. 4.120/4.122); e

iv. O OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/Nº102/2013, de 16.09.2013, por meio do qual foi solicitada à BSM - BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados ("BSM") planilha listando todas as operações realizadas pelos clubes (fls. 4.130-4.131).

11. Embora cause espécie a paralisação ocorrida entre dezembro de 2008 e março de 2013, verifico que os atos de investigação praticados entre maio e setembro de 2013 tiveram o condão de interromper a prescrição ordinária e evitaram o transcurso de cinco anos, que se ultimaria em novembro daquele ano.

12. Desta forma, rejeito a preliminar de prescrição quinquenal.

II.2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

13. Os Acusados alegam também ter ocorrido a prescrição intercorrente, prevista no artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99, pois, após a conclusão da inspeção, em novembro de 2008, não foram praticados quaisquer atos dentro do prazo legal de três anos.

14. Sobre o assunto, destaco que é entendimento da CVM⁴ e do CRSFN⁵ que a prescrição intercorrente não incide na fase investigativa, uma vez que o instituto pressupõe o início do processo administrativo sancionador propriamente dito, que, nessa Autarquia, se dá somente com a intimação dos acusados para apresentação de defesa, nos termos do artigo 8º, §1º, da Deliberação CVM nº 538/2008⁶.

15. No caso em tela, o processo administrativo sancionador se iniciou apenas em 2014, e, desde então, jamais ficou paralisado por três anos, motivo pelo qual também rejeito a incidência da prescrição intercorrente neste caso.

III. MÉRITO.

III.1. NEGOCIAÇÃO EXCESSIVA – “CHURNING”.

Introdução.

16. Conforme detalhado no relatório, a Geração Futuro é acusada de negociar excessivamente ativos que compunham a carteira de dez clubes de investimento⁷ por ela administrados, com o propósito de gerar receita de corretagem, em detrimento dos interesses dos condôminos dos respectivos clubes, em infração à norma do artigo 16, inciso VI, da Instrução CVM nº 306/99⁸.

17. A prática de negociação excessiva, internacionalmente conhecida como *churning*, é aquela realizada por pessoas que, atuando com controle sobre recursos de terceiros, realizam excessivos negócios em nome do cliente, visando não ao melhor interesse do cliente, mas a gerar taxas e comissões para si ou para outrem⁹. Trata-se de uma modalidade de fraude praticada no âmbito do mercado de capitais, que foi estudada e delimitada principalmente a partir da experiência do mercado norte-americano.

18. Em se tratando de processo administrativo sancionador que verse sobre negociação excessiva, entendo que cabe à acusação demonstrar não só (i) o **controle** que o acusado detinha sobre as operações cursadas em nome do investidor e (ii) o **giro excessivo** da carteira de investimentos, **à luz do perfil do cliente**, como também (iii) a **intenção** de gerar receitas de corretagem ou outras comissões. Vale ressaltar que **tanto o descasamento entre o giro da carteira e o perfil de cliente quanto ao elemento subjetivo podem ser demonstrados a partir de provas indiciárias**, desde que a acusação seja suportada por uma pluralidade de indícios sólidos e convergentes, que não sejam invalidados por contraindícios.

19. No caso em tela, a acusação de *churning* foi acertadamente restrita aos clubes cuja gestão, segundo os seus respectivos estatutos sociais, cabia à Geração Futuro. A acusada não contesta esse fato, razão pela qual entendo não haver dúvidas quanto ao **controle**, pela Geração Futuro, das carteiras que alegadamente foram giradas em excesso. Assim sendo, a discussão *in casu* acerca da prática de *churning* envolve avaliar se as carteiras dos referidos clubes foram, de fato, giradas em excesso com o intuito de gerar corretagens indevidas à acusada.

20. A acusação busca demonstrar o **giro excessivo** com base em dois indicadores usualmente mencionados na literatura especializada: (1) a **taxa de giro** da carteira (*turnover ratio*, "TR") e (2) a **razão custo sobre patrimônio** (*cost/equity ratio*, "C/E"). Adicionalmente, a acusação (3) aplica os indicadores de TR e C/E, inicialmente utilizados para analisar o comportamento de cada carteira em sua totalidade, também para os ativos mais negociados por cada clube.

21. O exame da jurisprudência local e internacional evidencia a importância que tais indicadores (TR e C/E) têm em casos instaurados para apurar a prática de *churning*. A literatura especializada demonstra que existem variadas formas de se calcular cada um desses indicadores. No Brasil, o estudo pioneiro acerca dos parâmetros para a caracterização da prática de *churning* no Brasil foi realizado pela Gerência de Análise e Estratégia da BM&FBovespa Supervisão de Mercados ("BSM") em 2011¹⁰ (doravante, o "Estudo BSM"). Em 2013, a Assessoria de Análise e Pesquisa ("ASA") da CVM elaborou o seu próprio estudo sobre indicadores de *churning* no mercado brasileiro¹¹ (o "Estudo ASA"). Conforme explorarei ao longo deste voto, os estudos da BSM e da ASA se valeram de metodologias diversas para o cálculo dos indicadores e chegam a resultados distintos.

22. **Por ora, cumpre ressaltar que os indicadores TR e C/E fornecem apenas indícios de *churning* e nem sempre bastarão para demonstrar a prática do ilícito.** O fato de a carteira ter sido mais movimentada do que a média de mercado (seja essa qual for) ou de os custos incorridos nas negociações terem consumido uma parcela expressiva do patrimônio investido não denotam, necessariamente, uma irregularidade. Afinal de contas, **o perfil do investidor (ou do fundo ou clube de investimento, conforme o caso) e os seus objetivos com aquele investimento são as melhores medidas para aferir se o giro foi, de fato, excessivo.** Segundo a doutrina:

"The excessive trading standard involves an in-depth probe into the relationship between the amount of trading activity and the customer's investment objectives. Such an inquiry necessitates an evaluation of the relationship between a qualitative characteristic (investor objectives) and a quantitative measurement (trading activity). The investor's qualitative individual objectives generally set the standard in any churning case. Different investors desire diverse financial risks and returns and therefore utilize a rich variety of investment vehicles such as bonds, bluechip stocks, speculative stocks, and options. For example, courts generally accept the proposition that the frequency of trades for a speculator naturally might exceed that for a person desiring a low-risk investment strategy and preservation of initial capital invested¹²."

23. Assim como nos Estados Unidos, a análise do giro da carteira para fins de apuração de responsabilidade em nosso país deve, necessariamente, ser realizada à luz do perfil do cliente e dos seus objetivos de investimento¹³. Naquele país, está consolidado o entendimento de que nenhum indicador pode ser considerado uma prova cabal e irrefutável de negociação excessiva, que possa ser indiscriminadamente aplicada em todos os casos¹⁴. Em linha com a jurisprudência estadunidense, a regra da FINRA (*Rule 2111(a) – Suitability*) expressamente prevê que nenhum teste, considerado isoladamente, define a negociação excessiva, ressaltando, todavia, que fatores como os indicadores de TR e C/E, bem como sucessivas compras e vendas de um mesmo ativo podem fornecer elementos para concluir que a regra de adequação quantitativa (*quantitative suitability*) foi descumprida¹⁵.

24. No Brasil, as regras específicas dos administradores de carteira e a regra geral que proíbe a realização de operações fraudulentas são menos explícitas, mas, delas se pode extrair que o perfil do cliente é uma medida importante na análise sobre o giro da carteira. Afinal de contas, as regras das Instruções CVM nº 494/2011 e 558/2015

proíbem operações realizadas com a finalidade de gerar receitas de corretagem, enquanto a Instrução CVM nº 08/79, no dispositivo aplicável ao caso, veda a utilização de “ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros”. Em ambos os casos, portanto, busca-se proibir que decisões relativas à movimentação da carteira sejam tomadas não no melhor interesse do cliente (logo, considerando seu perfil e os seus objetivos de investimento), mas, com o objetivo de beneficiar um terceiro (seja esse um gestor, um intermediário ou outro agente)¹⁶.

25. Diante do exposto, resta claro que uma taxa de giro e uma razão de custo sobre o patrimônio que excedem os indicadores apontados nos estudos especializados não são, necessariamente, provas irrefutáveis da prática de *churning* – embora usualmente se considere que, nessas situações, existe uma presunção relativa de irregularidade. Do mesmo modo, em outros casos, pode-se ao final concluir que a carteira foi girada em excesso, com o intuito de gerar corretagem, mesmo quando os indicadores de TR e C/E ficaram abaixo dos limites indicados nos estudos. Afinal de contas, **a análise de tais indicadores sempre deverá ser feita à luz do perfil do cliente e das características do caso concreto.**

26. Ao longo dos próximos parágrafos, irei analisar os argumentos da acusação e da defesa referentes aos três indicadores de *churning* empregados pela acusação. Os outros elementos trazidos pela acusação e pela defesa com o objetivo de reforçar ou refutar a tese de *churning* serão analisados em conjunto com os referidos indicadores, conforme aplicáveis.

1º Indicador: TR – Taxa de Giro da Carteira.

27. O primeiro indicador utilizado foi a taxa de giro da carteira, doravante referido simplesmente como “TR”, que mede a razão entre o total de operações realizadas¹⁷ e o patrimônio líquido do fundo (ou, como no caso, do clube de investimento). A acusação destaca os clubes que apresentaram TR acima de 8, taxa que, segundo o Estudo BSM, indica alta probabilidade de *churning*. De plano, ressalto que, de acordo com a jurisprudência da CVM¹⁸, a mera identificação de TR superior a 8 não é suficiente para caracterizar a negociação excessiva.

28. Dos 151 clubes de investimento analisados, 15 (9,27%) apresentaram TR acima de 8. A acusação apurou que três dos seis clubes com a maior taxa de giro da carteira (incluindo os dois que tinham os maiores TR) eram geridos por cotistas dos próprios clubes, que (na proporção de suas participações) arcavam com os custos por esses incorridos e não recebiam nenhuma remuneração em razão de tais despesas (como, por exemplo, mediante rebates). Por tal motivo, a acusação de *churning* não abrange esses três clubes. Outros três clubes de investimento – que, coincidentemente, eram os três outros clubes de investimento com maior TR – também foram excluídos dessa acusação, mas, por motivo diferente: a prescrição. A diferenciação decorre do fato de tais clubes não terem sido analisados nas diligências iniciais realizadas em 2007 e 2008.

29. Feitos esses expurgos, temos a princípio nove clubes da Família Gol. O fato de estarmos lidando com um número reduzido de clubes, pinçados de um universo maior, não desautoriza a tese da acusação, pois o artigo 16, inciso VI, da Instrução CVM nº 306/99 não se traduz em um dever de diligência, baseado em controles internos, sendo uma verdadeira vedação a que se gire excessivamente a carteira de um cliente com a finalidade de gerar receitas de corretagem.

30. De volta aos clubes da Família Gol, os nove clubes destacados apresentaram taxas de giro entre 8,22 (*Gol Igualdade*) e 10,34 (*Gol Doc*), com um TR médio de 9,34. Tais taxas são inegavelmente altas – o Estudo ASA, por exemplo, indica que, em 2007, o TR médio de um fundo de investimento ativo que perseguia o IBOVESPA era substancialmente inferior a esse patamar (o TR de referência para o terceiro quartil, considerando apenas fundos com esse perfil, era de 3,4). Não obstante, reconheço que a acusação em análise envolve taxas de giro substancialmente menores do que as vistas nos precedentes já analisados por esse Colegiado.

31. Por exemplo, o PAS CVM nº 24/2010 lidou com um caso onde a taxa de giro chegou a 68,3 em um ano (2006). Da mesma forma, o precedente mais recente – PAS CVM nº RJ2014/12921 – envolveu taxas de giro oscilando entre 24,29 e 42,89. Ou seja, o menor indicador TR que embasou os processos anteriores é mais de duas vezes superior à maior taxa de giro apontada neste caso. Esse fato, é claro, não afasta a acusação, mas, recomenda certa cautela quanto às conclusões que se pode extrair do referido indicador.

32. Ademais, o exame do giro requer uma análise do perfil de investimento dos clubes supostamente lesados. Esse tem sido um importante elemento em casos similares. Em um precedente, por exemplo, o Colegiado entendeu que o giro elevado não era um indício forte de irregularidade, dado que o suposto lesado era um fundo agressivo¹⁹. Reversamente, o Colegiado já considerou que o TR elevado era uma prova robusta da irregularidade em um caso que envolvia a gestão de carteira de um fundo de pensão “cujo horizonte de investimento é de longo prazo”²⁰.

33. Não há nos autos muitos elementos que nos permitem aprofundar esse exame. A acusação fundamenta a sua tese em uma manifestação da Geração Futuro (fls. 4421) em que essa afirma que os clubes e fundos por ela geridos teriam “forte componente fundamentalista”. Embora concorde que as taxas de giro das carteiras dos clubes da Família Gol não são, a princípio, compatíveis com uma estratégia fundamentalista, entendo que não se pode dar um peso excessivo à manifestação da Geração Futuro. Afinal de contas:

- (i) o trecho foi extraído de uma resposta dada a um ofício enviado em 2014, ou seja, muito após a data das operações aqui analisadas;
- (ii) a passagem em questão não tratava especificamente dos clubes investigados, mas, se referia genericamente a todos os clubes e fundos geridos pela acusada, um conjunto, naturalmente, heterogêneo; e
- (iii) a carta discutia a falta de homogeneidade nas taxas de corretagem cobradas pela Geração Futuro de diferentes veículos por ela geridos (fato que originou uma acusação específica, que será analisada no próximo item deste voto) e não fazia qualquer referência mais específica às estratégias de investimento – o trecho que menciona o “componente fundamentalista” tratava, de fato, da política de prestação de serviços da Geração Futuro e da estrutura por ela adotada a fim de garantir a confidencialidade das estratégias de posicionamento dos seus clubes e fundos.

34. Os estatutos sociais dos clubes de investimento da Família Gol²¹ também não explicitavam as suas respectivas estratégias de investimento. Analisando os referidos documentos, verifico que as suas carteiras eram predominantemente compostas por ações, e que não havia restrição estatutária à realização de operações de curto prazo. Em alguns casos, o estatuto permitia, inclusive, a realização de certas aplicações no

mercado de derivativos. Embora tais dados não sejam conclusivos, eles indicam que tais fundos poderiam ter um perfil mais agressivo. A defesa não aprofunda esse argumento e não traz outros elementos que nos permitam concluir que tais clubes tinham um perfil agressivo e compatível com as suas altas taxas de giro.

35. Em resumo, a análise do TR indica que (i) os clubes da Família Gol apresentaram taxas de giro elevadas, que excedem a taxa que, segundo o Estudo BSM, indica alta probabilidade de *churning*; (ii) as taxas apuradas são, contudo, substancialmente inferiores àquelas vistas em precedentes da CVM; e (iii) não há nos autos elementos que nos permitam aprofundar o exame sobre o perfil dos clubes, que é um dado de suma importância para essa análise. Feitas essas observações, passo ao exame do segundo indicador.

2º Indicador: C/E – Razão custo sobre patrimônio.

36. O segundo indicador utilizado pela acusação é o *cost/equity ratio*, ou, simplesmente, C/E. Em resumo, esse indicador busca medir a parcela do investimento que é consumida pelos custos de transação e é usualmente utilizado para complementar a análise feita com base no TR.

37. Nesse ponto, a acusação utiliza como baliza as conclusões constantes do Estudo ASA, que diverge substancialmente do Estudo BSM quanto aos parâmetros de identificação de custo excessivo. Com efeito, o Estudo BSM calcula o C/E com base na rentabilidade histórica do mercado acionário brasileiro e, a partir da rentabilidade média do IBOVESPA, entre os anos de 1996 e 2010, chega a um percentual de 21%.

38. O Estudo ASA, por sua vez, propõe que o C/E seja examinado através da comparação dos custos de negociação de um determinado fundo com o custo de negociação médio de fundos similares (considerando apenas as vendas realizadas no período). A ASA coletou informações referentes ao mercado brasileiro entre os anos de 2000 e 2012 e, em seu estudo, não apresenta um número único para cada indicador e sim patamares diferenciados, tanto em razão do comportamento médio do mercado a cada ano, quanto em função do perfil do investidor (o estudo considera fundos exclusivos e não exclusivos, e nesse caso, fundos com mais, ou menos, de 20 cotistas). O Estudo ASA chegou a um percentual de 4,1% no período relevante para a presente análise.

39. Dado que a própria acusação reconhece a incidência de prescrição em relação a alguns clubes de investimento e à falta de controle, pela Geração Futuro, do giro da carteira de outros clubes (vide item 31 acima), irei analisar somente o C/E dos clubes da chamada Família Gol. Noto, de plano, que além dos nove clubes que apresentaram TR acima de 8, a acusação inclui, ainda, o clube Gol Ideal, dado que tal clube possuía uma carteira praticamente idêntica e operava nos mesmos dias e em horários próximos aos demais. Estamos, portanto, falando de 10 clubes.

40. Nenhum desses clubes atingiu o C/E de 21% proposto no Estudo BSM. Utilizando a metodologia da BSM, vemos que o maior C/E dentre os clubes da Família Gol foi de 14,34% (Gol Doc) e que, na média, os referidos clubes apresentaram um C/E de 12,57% no período.

41. A acusação se baseia, contudo, no C/E calculado na forma prescrita no Estudo ASA e, conseqüentemente, toma como limite o percentual de 4,1% ali indicado. Analisando os fatos com base nessa metodologia, noto que dois clubes (Ideal e Igualdade) têm C/E abaixo desse percentual – inclusive o clube cujo TR era inferior a 8. Os demais clubes excedem o limite indicado no Estudo ASA, mas, não de modo significativo: o maior C/E, calculado na forma proposta pela ASA, foi de 4,95% (Gol Doc) e, na média, os clubes da Família Gol apresentaram um C/E ajustado de 4,14% no período.

42. A Geração Futuro alega que a acusação empregou metodologias variadas de forma seletiva, retirando de cada uma apenas os dados que favorecessem a sua tese. O argumento, a meu ver, não merece prosperar, pois a acusação se utiliza de estudos diferentes para tratar de dois indicadores (TR e C/E) que, embora sejam usualmente utilizados em conjunto, não se confundem.

43. A meu ver, ambas as análises – bem como outras metodologias – podem servir de elementos para subsidiar uma acusação dessa natureza. Em qualquer situação, os indicadores são apenas indícios, que podem ser refutados pela defesa, inclusive com base em outras estatísticas²². Especificamente com relação à análise do C/E, entendo que a metodologia utilizada no Estudo ASA é, de fato, mais robusta do que a do Estudo BSM, pois considera os custos de fundos semelhantes, ano a ano, e não a rentabilidade do mercado. Ressalto, todavia, que a relevância do Estudo ASA para casos futuros depende de uma atualização periódica dos indicadores de *churning*, de forma a que esses continuem refletindo as condições de mercado a cada período.

44. Segundo o Estudo ASA, a probabilidade de um fundo de investimento não exclusivo com mais de 20 cotistas ter, em 2007, um C/E de 4,1%, ou superior, era de 2,5%. Vale destacar que embora o referido estudo seja posterior aos fatos, ele considera as circunstâncias específicas do período analisado. Nessa perspectiva, é significativo notar que o C/E de oito dos dez clubes da Família Gol (ou seja 80%) excediam o marco indicado no Estudo ASA. Embora o referido estudo tenha se baseado em fundos de investimento em ações, ressalto que os clubes em tela tinham as suas carteiras geridas por um gestor profissional, e, em certos aspectos, estavam mais próximos de um fundo de investimento do que de um típico clube.

45. Por outro lado, não posso deixar de notar que, também na perspectiva do C/E, estamos diante de uma situação onde os valores não excedem de forma significativa os limites propostos nos estudos especializados, fato que distingue este caso dos precedentes da CVM sobre a matéria. Nesse sentido, noto que no PAS CVM nº SP2012/480, o *churning* foi caracterizado em uma carteira cujo C/E era de 37,4%, valor que, para fins de referência, foi então comparado com a rentabilidade média do Ibovespa (22,68%). O PAS CVM nº RJ2014/12921, por sua vez, indicava taxas C/E que variavam de 26,03% a 45,50%.

46. As conclusões a respeito do indicador C/E são, portanto, similares àquelas obtidas pela análise do TR: taxas altas, mas não tão elevadas como nos precedentes. No caso do C/E, vale ressaltar que os percentuais são bastante próximos daquele indicado como limítrofe no Estudo ASA, e que se considerássemos o estudo BSM, nenhum dos fundos atingiria o percentual considerado como indicador de irregularidade.

3º Indicador: "Análise Qualitativa" – TR e C/E de Ativos Específicos.

47. Por fim, a acusação calculou os indicadores TR e C/E individuais dos ativos mais negociados por cada um dos clubes de investimento da Família Gol. A acusação justifica o emprego de tal metodologia em um artigo de um advogado norte-americano, que argumenta que a análise do TR consolidado de uma carteira pode mascarar a negociação excessiva caso essa seja concentrada em alguns poucos ativos²³. Para ilustrar, vale transcrever trecho do referido estudo:

"Por exemplo, imagine que uma conta possui vinte e cinco ativos e que vinte e quatro são mantidos enquanto o vigésimo quinto é trocado a cada duas semanas por um ano. A conta teria sofrido negociações excessivas, mesmo que um cálculo convencional do giro apontasse um turnover ratio de 1. O cálculo do turnover ratio baseado no valor das ações negociadas – isto é, excluindo as vinte e quatro ações mantidas ao longo do ano – aponta um turnover ratio nesse exemplo de 26, o que reflete com mais precisão o padrão de negociações²⁴".

48. Dado que as carteiras dos clubes da Família Gol já apresentavam, no agregado, giros elevados, poder-se-ia objetar que as conclusões dessa análise, *in casu*, seriam evidentes – afinal de contas, quando uma carteira composta por ativos mais e menos negociados tem, em termos globais, um giro elevado, parece intuitivo concluir que os seus ativos mais negociados irão apresentar um alto TR. Todavia, parece-me que essas análises adicionais fornecem elementos importantes em casos como este, onde os indicadores classicamente utilizados, calculados com base na carteira, são elevados, mas, não excedem em muito os patamares usualmente indicados para verificar se houve negociação excessiva.

49. A análise dos indicadores individuais, calculados para os ativos mais negociados pelos clubes da Família Gol, traz elementos que corroboram a tese da acusação. Os dados constantes da tabela transcrita no relatório trazem, a meu ver, fortes indícios de que certos ativos eram negociados excessivamente, gerando corretagens substanciais. Senão vejamos:

- (a) considerando o giro do papel pelo patrimônio líquido correspondente àquele ativo, a taxa de giro do ativo mais negociado em cada um dos clubes variou de 27,88% (negócios de Gol Mil com GOAU4) a 109,00% (negócios de Gol Igualdade com GOAU4);
- (b) pelo menos um ativo de cada clube foi girado em montante superior ao patrimônio líquido total daquele clube; e
- (c) considerando as comissões gastas com um único papel dividido pela parcela do patrimônio líquido do clube correspondente àquele papel, vemos que o maior C/E por ativo variou de 31,88% (custos de Gol Mil com VALE5) a 113,36% (negócios de Gol Igualdade com GOAU4).

50. A defesa faz algumas objeções genéricas aos indicadores utilizados, mas, não traz elementos que refutem concretamente as metodologias empregadas pela acusação. Em minha avaliação, certos cuidados são necessários na utilização dos critérios usualmente empregados para analisar o giro de uma carteira para avaliar as negociações de um ativo específico, visto de forma destacada. É necessário, especialmente, refletir se as taxas e percentuais pensados para carteiras podem ser automaticamente replicados no exame isolado dos ativos que a compõem.

51. Essa ponderação parece especialmente pertinente no tocante ao TR, uma vez que os parâmetros de TR indicados, tanto no Estudo BSM quanto no Estudo ASA, foram construídos com base em carteiras, e é evidente que o TR dos ativos mais negociados de uma determinada carteira sempre será superior ao TR médio daquele portfólio. No tocante ao C/E, a preocupação perde relevância, dado que a metodologia do Estudo ASA parece igualmente aplicável a um ativo, ou a uma cesta de ativos – o cálculo considera a parcela do patrimônio investida em um ativo (ou em conjunto de ativos) que foi consumida em negociações com aquele ativo (ou, conforme o caso, conjunto de ativos).

52. De qualquer modo, no caso concreto, os indicadores TR e C/E obtidos na análise individualizada dos ativos mais negociados são bastante elevados e constituem, no meu entender, mais um sólido indício de que as carteiras foram, de fato, giradas em excesso com o objetivo de gerar corretagem, em detrimento do melhor interesse dos cotistas dos clubes da Família Gol.

53. Corroborando os dados, a acusação traz alguns exemplos de negócios que demonstram que a decisão de investimento dos referidos clubes frequentemente obedecia a uma sistemática de comprar o ativo, vendê-lo poucos dias depois, recomprar o mesmo ativo após um período e repetir tais passos sucessivamente, sem qualquer fundamentação econômica ou financeira minimamente plausível. A defesa, por sua vez, argumenta que as operações destacadas não corroborariam a tese da acusação. Nesse sentido, aponta que as operações constantes do relatório de acusação foram lucrativas para os clubes e que, no tocante às operações do Clube Gol Mina com ações do tipo VALE5, as posições desfeitas somente foram remontadas após períodos que variaram de 2 a 4 meses.

54. A meu ver, a defesa distorce o argumento da acusação, ao deslocar a análise temporal para o período entre a desmontagem da posição e o novo investimento no papel, enquanto a acusação se referia ao prazo de duração de cada posição naquele ativo. Nesse sentido, noto que os exemplos trazidos na acusação demonstram que as posições em certos papéis eram, muitas vezes, desmontadas em poucos dias. Esse padrão de negociação (*in-and-out trading*) é, reconhecidamente, outro forte indício da prática de *churning*²⁵.

55. Considerando que o acusado era um gestor profissional e que os ativos mais negociados eram, em sua maioria, ações de algumas *blue chips* brasileiras, parece-me que a simples indicação de que os clubes auferiram lucro nos negócios não é suficiente para afastar a acusação, especialmente quando se tem em mente que a bolsa brasileira experimentou uma forte valorização no período tratado neste PAS. A prática de *churning* “consome” parte da lucratividade dos clubes de investimento de modo que os seus cotistas poderiam ter auferido um retorno ainda maior se não tivesse ocorrido essa prática.

Sobre a rentabilidade dos clubes da Família Gol.

56. Antes de concluir essa parte, gostaria de tecer alguns breves comentários sobre a rentabilidade dos clubes da Família Gol no período coberto por este PAS. O resultado global do cliente não me parece determinante para um caso de *churning* – o fato de o cliente auferir lucro não afasta a possibilidade de prática de negociação excessiva, assim como o fato de uma carteira bastante movimentada ter prejuízo não permite concluir automaticamente pela prática da referida infração.

57. Os fatos tratados neste processo transcorreram em um período em que o mercado brasileiro experimentou uma forte valorização. Embora os clubes da Família Gol, exceto o Gol Doc, tenham obtido rentabilidade acima do IBOVESPA no período, já considerando os

custos de transação, a acusação demonstra que a rentabilidade dos papéis detidos pelos clubes foi, em geral, muito mais elevada do que a rentabilidade dos portfólios, e trazem elementos que demonstram de forma bastante contundente como os custos de transação consumiram parte substancial da rentabilidade de tais clubes.

58. Ressalto, por fim, não estar defendendo que uma carteira não possa ser girada, ou pretendendo estabelecer limites objetivos ao giro. Todavia, a meu sentir, **é razoável esperar que um gestor profissional avalie, a cada operação, se a expectativa de retorno adicional decorrente da mudança de investimento, descontados os custos incorridos naquela operação, é positiva.** Em casos como o presente – onde os clubes pagavam, em geral, corretagens altas e as carteiras eram giradas de forma expressiva para, ao final, voltarem a investir nos mesmos ativos – o gestor deve ter bases razoáveis para acreditar que a rentabilidade dos novos ativos da carteira durante um determinado período, descontados os custos incorridos com as operações cursadas aquele período, excede a rentabilidade que esperava do ativo que, no final das contas, pretende manter na carteira no longo prazo e que está sendo temporariamente substituído.

59. Nos autos, como visto, existem indícios substanciais de *churning* e não identifico nenhum contraindício que nos permita concluir que o elevado número de negócios foi realizado para beneficiar os cotistas dos clubes e não para gerar corretagem.

Conclusões sobre a acusação de giro excessivo.

60. Ante todo o exposto, entendo que a acusação logrou apresentar um conjunto de provas suficientemente robusto para sustentar uma condenação por infração ao artigo 16, inciso VI, da Instrução CVM nº 306/99.

61. Nesse sentido, ressalto novamente que os clubes da Família Gol apresentaram um TR superior à taxa apontada no Estudo BSM como indicativa de alta probabilidade de *churning*. Do mesmo modo, os clubes apresentaram percentuais de C/E bastante elevados.

62. Parece-me claro que, **olhando apenas para os índices, quanto maiores esses forem em um caso concreto, maior valor probatório deve a eles ser atribuído.** Nos casos em tela, tanto o TR quanto o C/E das carteiras não excederam de modo tão gritante os limites indicados nos estudos de referência, como nos precedentes já julgados pelo Colegiado. Por um lado, não se pode dar a esse fato um peso excessivo – os limites já foram calculados pensando em situações extremas, e considerar que a irregularidade somente resta caracterizada quando os marcos são em muito ultrapassados significa, em última medida, dizer que os referidos marcos pouco valem. Por outro lado, em casos menos extremos, a acusação deve, sempre que possível, buscar outros elementos de prova que corroborem a sua tese.

63. No meu sentir, a acusação se desincumbiu dessa tarefa, apresentando elementos adicionais que reforçam a convicção de que as carteiras dos clubes da Família Gol foram excessivamente giradas com o objetivo de gerar corretagem. Assim, voto pela condenação da Geração Futuro pela prática de *churning*.

III.2. NEGLIGÊNCIA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS CLUBES DE INVESTIMENTO AO NÃO NEGOCIAR DESCONTO NAS TAXAS DE CORRETAGEM GERADAS PELAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR ESTES CLUBES.

64. A Geração Futuro é acusada de ser negligente na defesa dos direitos e interesses de sete clubes de investimento que administrava no período, descumprindo, assim, o seu dever fiduciário enquanto administradora de carteira de valores mobiliários (artigo 16, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos da Instrução CVM nº 306/99). A acusação se baseia unicamente no fato de que certos clubes geridos pela Geração Futuro pagavam taxa de corretagem no valor correspondente ao percentual indicado na tabela Bovespa (0,5% sobre compras e vendas de valores mobiliários), enquanto outros clubes obtinham descontos que variavam entre 50 e 80% desse valor.

65. A Geração Futuro reconhece que os diferentes clubes pagavam taxas de corretagem distintas. Afirmou que, como regra geral, não concedia descontos aos clientes, e que os descontos eram concedidos por razões econômicas e comerciais, de maneira que optaram por conceder rebates para os clubes cuja gestão fosse da Geração Futuro, em clubes de investimento familiares, onde a possibilidade de discutir as suas convicções em relação ao mercado e empresas, sem que pudesse ter qualquer participação na decisão final de compra e venda de qualquer ativo.

66. A acusação entende que a Geração Futuro era também a intermediária dos negócios cursados pelos clubes – havendo aí um potencial conflito de interesses – e não diligenciou para reduzir os custos de corretagem justamente para os clubes de investimento que não eram ditos “exclusivos” ou “familiares”, ou seja, que tinham menos capacidade de barganhar com a corretora – que, repiso, era a própria gestora dos recursos.

67. A meu ver, **a acusação se apoia em entendimento correto, no sentido de que os deveres fiduciários inerentes à atividade de administração e gestão de recursos de terceiros se sobrepõem aos interesses próprios da corretora de valores mobiliários enquanto intermediária, exigindo que esta atue com diligência e lealdade, como se estivesse lidando com os seus próprios negócios**²⁶. Trata-se de norma que exige que a administradora priorize os direitos e interesses de quem a contratou em quaisquer situações que apareçam durante a relação contratual continuada e não somente em relação àquilo que foi expressamente pactuado.

68. Não obstante, não encontro nos autos provas de que a administradora tenha sido negligente na defesa dos interesses de determinados clubes por ela administrados. A acusação se fia apenas na demonstração de que alguns clubes que realizavam negociações expressivas não tinham desconto na taxa de corretagem, que era oferecido somente a clubes familiares e exclusivos. Diante desse fato, entendo que a acusação não logrou afastar os argumentos dos Acusados apresentados ainda na fase investigativa de que descontos praticados para determinados clientes se inseriam em uma lógica comercial, de conceder melhores condições de preço apenas para clientes com os quais a corretora tinha relacionamento diferenciado.

69. Com efeito, não vejo como, a partir do dever de diligência, construir um suposto dever de extensão de descontos a todos os clientes que não se encontram em situação idêntica. Essa interpretação, a meu ver, é a que melhor se amolda ao contexto de livre pactuação de preços que vige atualmente no mercado de capitais, especialmente naquilo que se refere à relação entre investidores e prestadores de serviços de intermediação de valores mobiliários e de administração e gestão de carteiras.

70. Analisando a tabela apresentada pela acusação, noto que de um total de 27 (vinte e sete) clubes apresentados, nove dos 12 clubes com maiores patrimônio líquido tinham algum desconto na taxa de corretagem, diferente dos outros 15 clubes menores, dos quais apenas três tinham o benefício. Essas informações, no meu entender, indicam que a acusada exerceu a sua atividade dentro de uma lógica comercial coerente, concedendo descontos de corretagem para clientes com maior poder de barganha e/ou para outros clientes com os quais mantinham relação específica.

71. Por outro lado, noto que dentre os clubes de investimento que não tiveram desconto na taxa de corretagem estão alguns dos clubes que mais realizaram operações no período. Esse fator, a princípio, costuma ter mais importância na negociação das taxas de corretagem do que o porte do investidor – o exemplo mais claro são investidores de alta frequência, cuja estratégia depende de descontos nas taxas e emolumentos. Não obstante, entendo que a constatação de que clubes que negociavam bastante não obtiveram descontos na taxa de corretagem é um elemento significativo, mas que não é suficientemente robusto para, sozinho, suportar uma acusação dessa natureza.

72. Noto, por fim, que existem diversos elementos que diferenciam esse caso do precedente invocado pela acusação. No Processo Administrativo CVM nº RJ2005/8510²⁷, a condenação da administradora e do seu respectivo diretor-responsável parece ter sido, em larga medida, motivada pelo fato de o diretor responsável da administradora ter admitido, ao depor, que nem procurou negociar a taxa de corretagem cobrada do fundo. Não vejo, portanto, como equiparar a situação aqui analisada com aquela tratada no precedente, que possuía provas substancialmente mais robustas.

73. Por todo exposto, entendo pela absolvição dos Acusados.

III.3. DEMAIS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS.

74. Por fim, a Geração Futuro e o seu diretor responsável pela supervisão dos clubes de investimento, Mauro de Mello, são acusados de infrações a certos dispositivos da Instrução CVM nº 40/84²⁸, conforme detalhado a seguir.

75. Em primeiro lugar, a acusação indica que alguns cotistas apresentaram percentual superior a 40% do total de cotas de clubes de investimentos, configurando infração ao artigo 7º da Instrução CVM nº 40/1984. Os Acusados reconhecem que quatro cotistas ultrapassaram esse limite, mas, alegam que em todos os casos a situação foi regularizada em, no máximo, cinco meses. A extrapolação do limite por quatro cotistas, em quatro clubes (num ambiente com mais de 300 clubes administrados), por período médio de dois meses, não parece de fato ter causado prejuízo aos cotistas do clube, ou ao mercado em geral, e denota alguma diligência dos Acusados em tomar as medidas necessárias para regularizar o problema.

76. A segunda infração apontada pela acusação decorre do fato de o clube de investimento Programado III ter tido 152 cotistas em janeiro e fevereiro de 2007, acima do limite de 150 cotistas previsto no artigo 9º da Instrução CVM nº 40/1984. Novamente, os Acusados reconhecem o problema, mas, apontam que a extrapolação em dois cotistas, em um único fundo, não pode ser considerada uma conduta grave, até porque perdurou por apenas dois meses e logo foi corrigida.

77. Os fatos relacionados às infrações dos artigos 7º e 9º da Instrução CVM nº 40/84 são incontroversos. Não obstante, entendo que embora estejam formalmente

caracterizadas, falta materialidade a essas infrações administrativas que justifique a atuação dessa Autarquia em âmbito de processo administrativo sancionador. Neste aspecto, ressalto que os Acusados corrigiram as irregularidades antes de questionamentos específicos da área técnica e nunca negaram as falhas pontuais. Da mesma forma, não encontro indícios de que se trata de falhas de controle internos disseminadas, mas, apenas problemas isolados e que não trouxeram maiores consequências a terceiros, ou ao mercado de capitais.

78. **Não são todas as infrações administrativas que apresentam justa causa para instauração de processo sancionador, mas, somente aquelas em que a punição se mostre como medida necessária e adequada, tendo em vista as finalidades da CVM em sua atividade sancionadora**²⁹. Nesse sentido, vale notar que o legislador prestigiou e reforçou, por meio da alteração do §4º do artigo 9º da Lei nº 6.385/1976 pela recente Lei nº 13.506/2017, a utilização de outros instrumentos de supervisão que se mostrem mais adequados a casos que envolvam pouca relevância da conduta e a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

79. Tendo em vista as peculiaridades do caso, todas convergentes a apontar a aplicação do princípio da insignificância, voto pela absolvição dos Acusados com relação às acusações relacionados às infrações aos artigos 7º e 9º da Instrução CVM nº 40/84. No meu sentir, mesmo a advertência, penalidade menos gravosa dentre as previstas na Lei nº 6.385/1976, se mostra desproporcional aos problemas ora examinados.

80. A terceira acusação formulada contra Geração Futuro e Mauro de Mello com base na Instrução CVM nº 40/1984 é a de infração ao artigo 4º, inciso III, do citado normativo. Trata-se de problema informacional, em razão de o Estatuto Social do clube de investimento Cézanne não indicar que a *Eagle Capital* recebia parte da remuneração paga pelo clube em razão da gestão de sua carteira. Sobre esse ponto, concordo com a defesa que a acusação deve ser afastada em respeito ao princípio da retroatividade da norma mais favorável.

81. Afinal de contas, a Instrução CVM nº 494/2011 eliminou a obrigatoriedade da informação da remuneração da administradora, ou da gestora, quando não forem encargos do clube. Extraí-se dos artigos 12 e 36 do mencionado diploma que a remuneração do gestor deve ser suportada pelo administrador, mas não há obrigatoriedade quanto ao seu detalhamento³⁰.

82. Vale frisar que a mencionada omissão estatutária imputável à Geração Futuro não se traduziu em prejuízo ao patrimônio do clube de investimento, aos seus cotistas ou mesmo a terceiros, pois, conforme se extrai da acusação (fls. 4.524) e do instrumento do contrato de prestação de serviços mantido entre a Geração Futuro e a *Eagle Capital* (fls. 4.026/4.028), a remuneração desta consistia em percentual da taxa de administração auferida pela primeira, calculada mensalmente sobre o patrimônio líquido do clube.

83. Ante o exposto, voto pela extinção da punibilidade no que se refere à infração ao artigo 4º, inciso III, da Instrução CVM nº 40/1984, por retroatividade de norma mais benéfica³¹, em prol da Geração Futuro e de Mauro de Mello.

IV. CONCLUSÃO

84. Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei nº 6.385/76, voto nos seguintes termos:

- i. Preliminarmente, pela rejeição das arguições de prescrição;

- ii. Pela condenação de Geração Futuro Corretora de Valores S.A. à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por infração ao artigo 16, inciso VI, da Instrução CVM nº 306/99³²;
- iii. Pela absolvição de Geração Futuro Corretora de Valores S.A. de todas as demais acusações contra ela formuladas; e
- iv. Pela absolvição de Mauro César Medeiros de Mello de todas as acusações contra ele formuladas.

É o voto.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
DIRETOR-RELATOR

¹PAS CVM nº 12/2013, julgado em 24.05.2016, Diretor-Relator Gustavo Tavares Borba; PAS CVM nº RJ2014/5807, julgado em 15.03.2016, Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes; PAS CVM números RJ2011/11073 e RJ2010/3695, ambos julgados em 15.12.2015, Diretor-Relator Pablo Renteria; PAS CVM nº 14/2009, julgado em 11.08.2015, Diretora-Relatora Luciana Dias; PAS CVM nº 04/2009, julgado em 11.06.2013, Diretora-Relatora Ana Dolores Moura Carneiro de Moraes; PAS CVM nº 03/2006, julgado em 01.12.2010, Diretor-Relator Eli Loria; PAS CVM nº RJ2008/2570, julgado em 12.05.2009, Diretor-Relator Marcos Barbosa Pinto.

² V. item 40 do mencionado relatório: “ao ser remunerado desta forma, o agente responsável pela gestão dos ativos do clube ensinaria eventual giro excessivo da carteira do mesmo com intuito de gerar receitas para si próprio”.

³ PJ Monet e Cézanne. Trata-se de acusação contra a *Eagle*, que, conforme indicado no relatório, está sendo apurada em processo apartado.

⁴ PAS CVM nº 22/94, Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 15.04.2004; PAS CVM nº 11/2002, Diretora-Relatora Luciana Pires Dias, julgado em 26.02.2013; PAS CVM nº 08/2012, Diretora-Relatora Ana Novaes, julgado em 16.12.2014; PAS CVM nº 23/2010, Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 04.11.2014; PAS CVM nº RJ2010/3695, Diretor-Relator Pablo Waldemar Renteria, julgado em 15.12.2015.

⁵ Acórdão CRSFN nº 11434/15, Recurso nº 11411, 375ª Sessão, Conselheiro-Relator Bruno Meyerhof Salama, julgado em 27.01.2015; Acórdão CRSFN nº 285/2017, Recurso nº 13.600, 403ª Sessão, Conselheiro-Relator Flávio Maia Fernandes Dos Santos.

⁶ §1º - Considerar-se-á instaurado o processo administrativo com a intimação dos acusados para apresentação de defesa, nos termos do art. 13 desta Deliberação.

⁷ Quais sejam: *Gol Doc*, *Gol Family*, *Gol Mil*, *Gol Colina*, *Gol Meta*, *Gol Acadêmico*, *Gol Barriga Verde*, *Gol Mina*, *Gol Igualdade* e *Gol Ideal*. Em benefício da síntese, doravante irei me referir a esse conjunto de clubes de investimento como os clubes da “Família Gol”.

⁸ Atualmente, as normas da CVM que repelem a prática do *churning* são previstas no artigo 17, inciso VII, da Instrução CVM nº 558/2015 e artigo 20, inciso III, da Instrução CVM nº 494/2011 e no item II, “b”, da Instrução CVM nº 08/79 (operação fraudulenta), proibido pelo item I daquele mesmo normativo. Os comandos da Instrução CVM nº 558/2015 – assim como os da Instrução CVM nº 306/99, que a antecedeu – são aplicáveis diretamente aos administradores de carteira de valores mobiliários. Já a proibição de realizar operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários é aplicável a todas as pessoas que realizam operações no mercado, independentemente de atuarem em nome próprio ou de terceiros, ou de terem autorização para exercer atividade sujeita a registro.

Vale lembrar também a norma contida no artigo 2º, §5º, da Instrução CVM nº 539/2013, que, embora não se refira diretamente à mencionada irregularidade, repele a sua prática ao proibir as pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários, de recomendar produtos, serviços ou operações que, isoladamente, ou em conjunto, impliquem custos excessivos e inadequados ao perfil do cliente.

⁹ Carras v. Burns, 516 F.2d 251, 258 (4th Cir. 1975): “*Churning occurs when a broker, exercising control over the volume and frequency of trading, abuses his customer's confidence for personal gain by initiating transactions that are excessive in view of the character of the account.*” Neste voto, farei constantes referências à doutrina, à jurisprudência e à regulação dos Estados Unidos acerca da matéria. Embora existam diferenças substanciais entre o sistema norte-americano e o brasileiro, podemos nos aproveitar da experiência daquela jurisdição desde que tomados os devidos cuidados de adaptação. Com relação ao *churning*, a experiência

brasileira é relativamente recente e a jurisprudência é ainda incipiente, enquanto nos Estados Unidos o assunto é discutido há mais de quatro décadas.

¹⁰ Gerência de Análise e Estratégia da BM&FBovespa Supervisão de Mercados. *Relatório de Análise 001/2011 - Determinação dos parâmetros para a caracterização da prática de churning no Brasil*. Julho/2011. Disponível em: <http://www.bsm-autorregulacao.com.br/assets/file/noticias/REL-GAE-01-2011-Churning.pdf>. Acesso em 15.12.2017.

¹¹ *Indicadores de Churning* (Julho/2013). Disponível em: http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/Estudo_Churning.pdf.

¹² WINSLOW, Donald Arthur & ANDERSON, Seth C. "A Model for Determining the Excessive Trading Element in Churning Claims". In *North Carolina Law Review*, Volume 68-2 (1990). Disponível em: <http://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3287&context=nclr>. Acesso em 28.12.2017.

¹³ Vide o trecho de *Carras v. Burns*, 516 F.2d 251, 258 (4th Cir. 1975), transcrito na nota de rodapé 10 acima. No mesmo sentido, e.g., *Rizek vs. SEC*, 215 F.3d 157 (1st Cir. 2000): "*Churning is commonly said to have three elements: (1) control of the customer's account by the broker, either explicit or de facto; (2) excessive trading in light of the customer's investment objectives; and (3) scienter -- the required state of mind for liability under Section 10(b) and Rule 10b-5*" (sem grifos no original).. No mesmo sentido, *Hotmar v. Lowell H. Listrom & Co.*, 808 F.2d 1384, 1385 (10th Cir. 1987): "*a broker may be held liable for violation of federal securities laws once an investor proves that: (1) the trading in his account was excessive in the light of his investment objectives; (2) the broker in question exercised control over the trading in the account; and (3) the broker acted with an intent to defraud or with willful and reckless disregard for the investor's interests.*" (sem grifos no original).

¹⁴ *Costello v. Oppenheimer & Co.*, 711 F.2d 1361, 1369 n.l (7th Cir. 1983): "*Whether a particular turnover rate is excessive depends on the objectives of the customer.*" A doutrina também faz essa importante ressalva: "*Because determination of an excessive turnover rate depends on the nature of the account and the circumstances of the investor, it is impossible to state definitively how many times an account must be turned over during a given period before trading will be deemed excessive*". O'HARA, Patricia A. *The Elusive Concept of Control in Churning Claims under Federal Securities and Commodities Law* (1987), p. 1981. Disponível em http://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/875/. Acesso em 28.12.2017.

¹⁵ FINRA Rule 2000. Duties and Conflicts. 2100. Transactions with Customers. 2110. Recommendations. 1111. Suitability. Supplement Material – 5. Components of Suitability Obligations: "*No single test defines excessive activity, but factors such as the turnover rate, the cost-equity ratio, and the use of in-and-out trading in a customer's account may provide a basis for a finding that a member or associated person has violated the quantitative suitability obligation.*" Disponível em: http://finra.complinet.com/en/display/display_main.html?rbid=2403&element_id=9859. Último acesso em 15.12.2017.

¹⁶ Não irei, neste voto, me aprofundar na discussão sobre as eventuais diferenças do elemento subjetivo constante das normas aqui invocadas, uma vez que não se trata de matéria relevante para o deslinde do caso em análise.

¹⁷ Há diferentes formas de calcular o TR, que podem considerar, por exemplo, apenas as compras ou as vendas. Sobre o assunto, cf. Estudo ASA.

¹⁸ PAS CVM nº RJ2014/12921, julgado em 10.02.2017, Diretor-Relator Pablo Waldemar Renteria; PAS CVM nº 24/2010, julgado em 27.5.2015, Diretora-Relatora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes; e PAS CVM nº SP2012/480, julgado em 27.10.2014, Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

¹⁹ PAS CVM nº 34/00, julgado em 16.09.2004, Diretor-Relator Wladimir Castelo Branco Castro.

²⁰ PAS CVM nº 24/2010, julgado em 24.05.2014, Diretora-Relatora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes.

²¹ Os estatutos sociais dos clubes de investimento encontram-se, respectivamente, em: *Gol Mil* (fls. 74), *Gol Acadêmico* (fls. 120), *Gol Igualdade* (fls. 125), *Gol Meta* (fls. 130), *Gol Family* (fls. 150), *Gol Ideal* (fls. 155), *Gol Colina* (fls. 160), *Gol Doc* (fls. 163), *Gol Barriga Verde* (fls. 167) e *Gol Mina* (fls. 177).

²² No Processo Administrativo Sancionador CVM Nº RJ2015/1591, julgado em 26.09.2017, tive a oportunidade de tratar de provas estatísticas e da possibilidade de se utilizar, desde que de forma devidamente embasada, diferentes variáveis em casos distintos. Embora o contexto fosse diferente (lá, discutimos a utilização de diferentes metodologias para demonstrar a ocorrência de "oscilação atípica" para fins da Instrução CVM nº 358/2002), as observações feitas naquele caso me parecem, com as devidas adaptações, igualmente aplicáveis aqui: "66. (...) entendo que nenhuma metodologia estatística é, por si só, suficiente para concluirmos pela atipicidade do comportamento do mercado. Essa análise deve, necessariamente, ser feita de forma circunstanciada, considerando as características do caso concreto. As estatísticas utilizadas pelas áreas técnicas em acusações dessa natureza são, portanto, elementos que permitem analisar de forma crítica o comportamento do valor mobiliário, mas, as conclusões fornecidas por tais modelos sempre poderão ser afastadas em razão de outros argumentos, inclusive de natureza estatística. 67. Entendo, portanto, que a acusação não é obrigada a utilizar sempre os mesmos meios de prova em casos instaurados para apurar a eventual falha na divulgação de fato relevante em razão de oscilação atípica. De fato, a adoção de um único critério estatístico, objetivamente verificável, facilitaria o cumprimento da norma, mas não seria fiel ao seu espírito, que é de evitar situações de assimetria informacional relevante no mercado."

²³ MCCANN, Craig. *Churning Revisited: Trading Costs and Control*. Disponível em: <http://www.slacg.com/pdf/workingpapers/Churning%20Revisited.PDF>. Acesso em 15.12.2017.

²⁴ Idem, p. 5. Tradução livre. No original: "For example, imagine an account has twenty-five securities and that twenty-four are held while the twenty-fifth security is switched out every two weeks for a year. The account would have been excessively traded even though a conventional turnover calculation would yield a turnover ratio of 1. Calculating a turnover ratio based on the value of the securities traded - that is, excluding the twenty-four securities held throughout the year - yields a turnover in this example of 26, which more accurately reflects the standardized level of trading".

²⁵ De acordo com a jurisprudência norte-americana, o *in-and-out trading* é caracterizado pela venda de todo ou de parte do portfólio do cliente, seguida do reinvestimento dos recursos daí decorrentes em outros valores mobiliários, os quais são, então, também rapidamente alienados ("*sale of all or part of a customer's portfolio, with the money reinvested in other securities, followed by the sale of the newly acquired securities*"). O *in-and-out trading* é expressamente mencionado na regra do autorregulador (FINRA) como indicativo de irregularidade, ao lado dos indicadores de TR e C/E. Vide nota 17 acima. Costello v. Oppenheimer & Co., 711 F.2d 1361, 1369 n.9 (7th Cir. 1983). De acordo com a FINRA, "a broker's use of in-and-out trading ordinarily is a strong indicator of excessive trading". V. *Additional Guidance on FINRA's New Suitability Rule*, nota 68. Disponível em http://finra.complinet.com/en/display/display.html?rbid=2403&element_id=10722&print=1. Acesso em 28.12.2017.

²⁶ Nesse aspecto, vale notar que a Instrução CVM nº 494/2011, posterior aos fatos, determinou que a atividade de administração de clubes de investimento deve ser realizada por "*sociedade corretora, sociedade distribuidora, banco de investimento ou banco múltiplo com carteira de investimento*", sendo que o diretor responsável pode cumular a atividade com outras obrigações e responsabilidades, desde que não haja conflito entre elas (artigo 18). A CVM, portanto, com o advento da mencionada Instrução, continuou a não proibir a concentração das atividades de administração, gestão e intermediação em uma única pessoa jurídica, mas buscou mitigar potenciais conflitos de interesse, exigindo a indicação de diretores diferentes para atividades potencialmente conflitantes.

²⁷ Processo Administrativo CVM nº RJ2005/8510, julgado em 04.04.2007, Relatora-Diretora Maria Helena de Santana.

²⁸ O descumprimento de quaisquer das normas contidas na Instrução CVM nº 40/84 constitui infração grave para os efeitos do artigo 11, §3º, da Lei nº 6.385/76.

²⁹ No mesmo sentido, os PAS CVM nº 14/03, julgado em 15.05.2007, Diretor-Relator Pedro Marcilio de Sousa; PAS CVM nº 2002/6982, julgado em 18.12.2003, Diretora-Relatora Norma Janssen Parente; PAS CVM nº RJ2013/4328, julgado em 01.09.2015, Diretor-Relator Pablo Waldemar Renteria.

³⁰ A respeito, vale mencionar o item 8.2.1 do Regulamento de Clube de Investimento da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (entidade administradora de mercado organizado), aprovado pela CVM nos termos dos artigos 39 e seguintes da Instrução CVM nº 494/2011. *In verbis*: 8.2.1. A taxa de administração destina-se a remunerar o Administrador pela atividade de administração do Clube de Investimento e compreenderá o valor relativo às atividades de gestão, consultoria de investimentos, tesouraria, controle e processamento dos Ativos, escrituração da emissão e do resgate de Cotas, bem como qualquer outro serviço contratado pelo Administrador. Disponível em http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulamentos-e-manuais/. Acesso em 17.11.2017.

³¹ O entendimento supra se encontra em conformidade com os precedentes desta CVM. Por exemplo, no PAS CVM nº 38/00, foi apreciada especificamente a possibilidade da retroatividade benéfica de Instrução CVM, concluindo-se pela sua aplicação e pela consequente extinção da punibilidade. Vejamos: *O artigo indicado dispunha que um título ou valor mobiliário de renda variável de uma companhia só poderia ser negociado no mercado em que se encontra registrado. No caso sob análise, não obstante o fato de as ações TELMA PNA se encontrarem listadas na SOMA, foram vendidas pela Float ao CIBRIUS no mercado de balcão não organizado, em flagrante desacordo com os termos da norma supracitada. Ocorre, porém, que o artigo 2º da Instrução CVM nº 202/93 foi revogado pela Instrução CVM nº 344/2000, extinguindo-se, assim, a punibilidade por infração àquele dispositivo, à luz do princípio da retroatividade da lei mais favorável, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal.* (PAS CVM nº 38/00, Diretor-Relator Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 02.04.2003).

³² Para fins de dosimetria, acompanho aqui os critérios utilizados no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/2797, julgado em 27.09.2016, Diretor-Relator Pablo Renteria.